



Roj: **SAP S 267/2019 - ECLI:ES:APS:2019:267**

Id Cendoj: **39075370022019100130**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Santander**

Sección: **2**

Fecha: **02/05/2019**

Nº de Recurso: **1013/2018**

Nº de Resolución: **242/2019**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **BRUNO ARIAS BERRIOATEGORTUA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

SENTENCIA n.º 000242/2019

Ilmo. Sr. Presidente:

Don José Arsuaga Cortázar.

Ilmos. Sres. Magistrados:

Don Bruno Arias Berrioategortua.

Doña Milagros Martínez Rionda.

=====

En la Ciudad de Santander a dos de mayo de dos mil diecinueve.

Vistos en trámite de apelación ante esta Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de Cantabria los presentes Autos de Juicio Ordinario número 101 de 2018, (Rollo de Sala número 1013 de 2018), procedentes del Juzgado de 1ª. Instancia número 1 de los de Laredo, seguidos a instancia de don Juan Luis contra don Juan Ramón .

En esta segunda instancia han sido parte apelante: don Juan Ramón representado por la Procuradora Sra. Santo Domingo Alfonso y asistido por el Letrado Sr.Huidobro Quirce; y parte apelada don Juan Luis , representado por la Procuradora Sra. Rodríguez González y asistida por la Letrada Sra. Yelamos Cepeda.

Es ponente de esta resolución el Ilmo. Sr. Magistrado Don Bruno Arias Berrioategortua.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de los de Laredo y en los autos ya referenciados, se dictó Sentencia con fecha 8 de octubre de 2018 de cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "**FALLO: ESTIMAR la demanda formulada por la procuradora Dª Lucía**

Rodríguez González, en nombre y representación de D. Juan Luis , contra D. Juan Ramón , condenando al demandado, a abonar al demandante, la cantidad de 7.260€, más el interés legal de la cantidad a cuyo pago ha resultado condenado, desde la fecha de interposición de la demanda hasta la fecha de la presente resolución, momento a partir del cual y hasta el completo pago se incrementará en dos puntos el interés legal (artículo 576 de la Ley 1/2000, de 7 de enero Enjuiciamiento Civil), con imposición de costas al demandado".

SEGUNDO: Contra dicha Sentencia, la representación de la parte demandada interpuso en tiempo y forma recurso de apelación, que fue admitido a trámite por el Juzgado; y tramitado el mismo, se remitieron las actuaciones a la Ilma. Audiencia Provincial, previo emplazamiento de las partes, habiendo correspondido por turno de reparto a esta Sección Segunda, donde se ha deliberado y fallado el recurso el día señalado, quedando pendiente de dictarse la resolución correspondiente.

TERCERO: En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales, excepto el plazo para resolver el recurso, en razón a la existencia de otros asuntos civiles señalados con anterioridad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se admiten los de la sentencia de instancia, en tanto no sean contradictorios con los que a continuación se establecen, y

PRIMERO: El objeto de este procedimiento está determinado por la reclamación de 7.260 euros formulada por el demandante titular de una empresa inmobiliaria contra el demandado en virtud del contrato de comisión para la venta en exclusiva de una vivienda de éste, en la que se convino que el comitente vendría obligado a obligar a la comisionista una cantidad equivalente al importe de los honorarios "si la compraventa no llegara a perfeccionarse o se frustrase por causa imputable al CLIENTE", que es la tesis sostenida por la parte actora.

La sentencia ha estimado íntegramente la demanda y contra ella se alza la parte demandada y condenada. Con su recurso la parte apelante pretende la desestimación de la demanda y su definitiva absolución. Sobre el escrito de interposición del recuso hay que indicar que aunque comienza alegando que el mismo se fundamenta en errores en la valoración de la prueba y falta de motivación del fallo (sic), se advierte que la disconformidad con la sentencia de instancia se fundamenta en unos motivos que pueden sintetizarse en los siguientes:

- a) Ineficacia contractual por la existencia de cláusulas abusivas, por falta de transparencia y por falta de reciprocidad;
- b) Error en la valoración de la prueba en lo relativo a la perfección del contrato;
- c) Indebida aplicación de la normativa sobre IVA.

Este va a ser el orden a seguir para el examen del recurso de apelación, señalando ahora que la queja por falta de fundamentación de la sentencia carece de rigor, pues la resolución permite, como se explica en el siguiente fundamento, conocer los motivos de la decisión judicial.

En cualquier caso, y a modo de antecedente indicar por último que la parte apelada no sólo se opone al recurso e interesa la confirmación de la sentencia de instancia, sino que interesa en primer lugar la inadmisión del recurso por infracción de los arts. 458 y 459. 459 LEC.

SEGUNDO: En relación con las alegaciones de la parte apelada acerca de la concurrencia de causas de inadmisión, porque no se cumple con los requisitos previstos en los arts. 458.2 (no citar el recurso los pronunciamientos de la sentencia que impugna) y 459 LEC (no citar, al alegarse infracción de normas o garantías procesales por falta de fundamentación de la sentencia apelada, las normas que se consideren infringidas).

Respecto de la denunciada infracción del art. 458.2 LEC, la jurisprudencia viene manteniendo un criterio flexible en la interpretación de los requisitos del apartado 2, y en concreto acerca de la interpretación del requisito de la indicación del "pronunciamiento que impugna" la parte apelante. Así, se suele decir que el requisito debe entenderse cumplimentado cuando el escrito de apelación, tras su lectura conjunta, permita deducir con claridad cuáles son realmente los pronunciamientos que se combaten.

En tal sentido, al examinar dichos requisitos, el Tribunal Supremo mantuvo una línea flexible en su aplicación como se desprende de las Sentencias núm. 48/2011, de 15 de febrero de 2011, núm. 329/2010, de 25 de mayo de 2010, núm. 22/2010, de 29 de enero de 2010, núm. 810/2009, de 23 de diciembre de 2009, núm. 543/2009, de 15 de julio de 2009 y núm. 200/2009, de 30 de marzo de 2009.

Pues bien, basta la obligada lectura del escrito de recurso, para concluir que se llenan los requisitos previstos en el precepto, que la parte apelada y el tribunal de apelación están en condiciones de conocer qué es lo recurrido, -la estimación de la demanda y consiguiente imposición de las costas- y pueden por tanto y respectivamente, defenderse del recurso y resolverlo con todas las garantías.

Ciertamente no puede decirse lo mismo respecto del motivo enunciado como falta de fundamentación del "fallo". El apelante no argumenta en ningún momento acerca de este vicio y, desde luego no menciona las normas que considera infringidas por esa razón por la juez a quo. No obstante, un principio pro actione impone no ser rigurosamente exigentes porque es sabido que la falta de motivación supone la infracción de un deber judicial asentado en diversas y conocidas normas jurídicas (24 y 120 CE, 11 y 248 LOPJ o 218 LEC), y la falta de mención de esas normativa no impide ni dificulta tampoco la defensa del recurso y su resolución con todas las garantías. En cualquier caso, la sentencia está, en líneas generales, suficientemente motivada, es decir, contiene los elementos y razones de juicio que permiten conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que

fundamentan la decisión, cuestión completamente diferente es que la parte apelante esté disconforme con ellos. La excepción a la motivación generalizada está constituida por la decisión no explicada en la sentencia de porqué la condena equivale a honorarios más IVA y no sólo a aquellos, omisión que en cualquier caso se salva en esta alzada en el fundamento jurídico sexto de esta resolución indemnización

Por lo tanto lo que procede, como ya se adelantó, es la desestimación de este motivo del recurso de apelación.

TERCERO: Como ya se ha indicado, uno de los motivos del recurso deducidos del conjunto del escrito de interposición del recurso de apelación es el relativo a la ineficacia del contrato de gestión de venta en exclusiva por contener éste cláusulas abusivas. Este ha de ser, por evidentes razones de orden, el primero de los motivos a resolver.

De las diversas alegaciones del apelante -por cierto mera reiteración de las contenidas en su escrito de contestación- se deduce que éste viene a sostener, en primer lugar, que una serie de cláusulas, de la que sólo se identifica *"la cláusula referida a la exclusividad... se debe considerar nula por falta de transparencia"*.

El control de transparencia supone por un lado, el llamado control de incorporación formal que supone la exigencia de legibilidad, y en segundo lugar, la comprensibilidad de la cláusula. La legibilidad supone que las cláusulas aparezcan suficientemente destacadas y que su dimensión sea adecuada, mientras que la comprensibilidad requiere que las cláusulas tengan una redacción materialmente comprensible, que no sean "ambiguas u oscuras" (art. 5 LCGC) y sean "concretas, claras y sencillas" (art. 80 TR).

La revisión del contrato aportado permite comprobar que el mismo prevé que el cliente *"...ENCARGA LA VENTA en la modalidad de exclusiva...";* que el cliente *"...se obliga a no encargar la gestión a ninguna otra distinta a la Inmobiliaria durante la vigencia del presente contrato, ni hacer gestiones directas tendentes a la venta del inmueble al margen de la Inmobiliaria sino a través de ésta...";* o cuáles han de ser las consecuencias *"Dado el carácter de exclusiva del presente contrato"* si el cliente vendiera directamente.

La cláusula de exclusividad que se deduce de esas menciones contractuales colma suficientemente las exigencias del doble control de transparencia, puesto que es legible y lo suficientemente claras para que una persona media sea capaz de comprender su contenido, permitiendo al demandado conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizado a cambio de la prestación económica que se quiere obtener; como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo.

Por lo tanto este motivo del recurso debe ser desestimado.

CUARTO: El recurrente tilda también de abusiva por falta de reciprocidad la cláusula que establece el derecho al cobro de la comisión si se incumple el pacto de exclusividad. El demandado parece referirse a la siguiente cláusula:

EL CLIENTE deberá abonar a la INMOBILIARIA una cantidad equivalente al importe de los honorarios pactados en contraprestación a los servicios prestados hasta ese momento así como por el resto de los servicios contratados y que la INMOBILIARIA está obligada a prestar según este contrato, en los siguientes casos:

Si EL CLIENTE rechazase de un cliente comprador una oferta de compra que se ajuste a las condiciones de venta fijadas en este contrato.

Si la compraventa no llegara a perfeccionarse o se frustrase por causa imputable a EL CLIENTE.

Como es sabido, el control de abusividad de las cláusulas predisuestas en contratos concertados con consumidores combina la aplicación de una cláusula general y un listado de cláusulas específicas a considerar en todo caso abusivas.

En lo que a qué ha de entenderse por cláusula abusiva en general, el art. 3 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 las define como aquellas "cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente ... si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato", y el art. 82 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios como "todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato"

Por otro lado las denominadas "listas negras" de cláusulas en todo caso abusivas se contienen en el anexo de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 y en el art. 87 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Es claro que la cláusula transcrita no se corresponde con ninguna de las de esos listados.

Y desde el punto de vista de cláusula abusiva en general hay que destacar que no basta la simple falta de reciprocidad. La cláusula analizada no será abusiva por establecerse solo para caso de incumplimiento obligacional del consumidor y no para el caso de incumplimiento obligacional del profesional. Para que pueda calificarse de abusiva es además necesario que contrarie las exigencias de la buena fe y cause en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que no se da en este supuesto en que la compensación surge por la negativa del cliente a concertar el contrato efectivamente conseguido a través de unas gestiones exitosas realizadas por la agencia inmobiliaria.

Por lo tanto este motivo del recurso debe ser desestimado.

QUINTO: A lo largo de su recurso la parte apelante aduce la comisión por la juez a quo de un error en la valoración de la prueba en lo relativo a sus razones para no suscribir el contrato con la compradora localizada por la empresa inmobiliaria. Así sostiene que la oferta de compra del 23 de octubre, única hecha por el precio previsto en el contrato de mediación para la venta, ni fue seguida del contrato de arras que la agencia estaba facultada para efectuar, ni tampoco le fue comunicada. Resulta a estos efectos irrelevante si hubo o no una oferta de fecha anterior que no se ajustara por no alcanzar el precio convenido, a las previsiones del contrato tal y como parece sugerir la parte apelante.

Una nueva revisión de la prueba practicada revela que como consecuencia del contrato de mediación, la inmobiliaria desplegó una actividad comercial que resultó finalmente exitosa al localizar a una compradora, D^a Micaela, dispuesta a adquirir la vivienda del demandado por el precio que él exigió; que el demandado vendedor tuvo conocimiento de la realidad de esa oferta porque así se lo comunicaron las empleadas del demandante, D^a Joaquina y D^a Natalia, un sábado, quedando en fijar al lunes siguiente el día concreto para formalizar el contrato de compraventa y pagar una señal, pero a partir de ese momento el vendedor no volvió - como declaró D^a Joaquina - a dar señales de vida. Así se deduce de la valoración de los testimonios de las tres señoras mencionadas, coincidentes en lo sustancial pese a referirse a unos hechos ocurridos dos años antes y debiendo además destacarse que no cabe albergar duda alguna de parcialidad en dos de ellas, la compradora y D^a Natalia, que ya no trabaja para el actor.

Consecuentemente con esos hechos probados, este tribunal, al igual que el de la instancia, advierte que la frustración del contrato de compraventa intermediado por la parte actora es imputable al demandado vendedor, que teniendo conocimiento del éxito de la gestión encomendada, se desentendió del negocio en el último instante.

No le excusa que la inmobiliaria no suscribiera por él el contrato de compraventa (lo que las partes denominan contrato de arras o señal preparatorio del de compraventa) y recogiera en su nombre las arras que la vendedora entregara, porque al margen de que esa previsión lo era de una facultad (*El CLIENTE ... autoriza expresamente a la Inmobiliaria para que efectúe en su nombre contrato de arras...*), cabe razonablemente entender a la vista de la prueba testifical, que, tras la última visita, la compraventa se formalizaría directamente con el demandado vendedor.

Por lo tanto este motivo del recurso debe ser desestimado.

SEXTO: Por último, la parte apelante suscita la cuestión del IVA, alegando debiendo el cliente abonar a la inmobiliaria "una cantidad equivalente al importe de los honorarios pactados en contraprestación a los servicios prestados hasta ese momento así como por el resto de los servicios contratados y que la INMOBILIARIA está obligada a prestar según este contrato", cuando el cliente rechazase una oferta de compra ajustada a las condiciones estipuladas o la compra se frustrase por causa imputable al cliente, la obligación debe entenderse en sus estrictos términos, sin gravarla con IVA alguno por tratarse de una indemnización.

Tampoco aquí asiste la razón en este caso al recurrente pues lo cierto es que, al margen de la literalidad del contrato que en este punto se refiere a los "honorarios" y en otros a los "honorarios con el IVA correspondiente", lo que se trata es de retribuir "los servicios prestados hasta ese momento" que por el éxito alcanzado en la intermediación parece claro que eran la totalidad o, al menos, la inmensa mayoría y los más relevantes de la gestión encomendada, por lo que no puede considerarse una mera indemnización de daños y perjuicios que no devenga IVA.



En cualquier caso, el perceptor del IVA no es el destinatario final de ese impuesto, sino un mero gestor en la recaudación y la cantidad que ha de percibir bajo ese concepto ha de ingresarlo en la Agencia Tributaria, no consolidándolo en su patrimonio.

En consecuencia, tampoco procede, por este motivo, la estimación de este recurso.

SÉPTIMO: La desestimación del recurso justifica la imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante (art. 398 LEC).

Así, en ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos ha conferido la Constitución Española, y en nombre de Su Majestad el Rey,

FALLAMOS

- 1) Desestimar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de instancia;
- 2) Imponer a la parte apelante las costas de esta alzada.

Esta Sentencia no es firme y contra ella caben los recursos extraordinarios de casación y por infracción procesal, para ante el Tribunal Supremo, que deben interponerse en legal forma ante esta Audiencia en plazo de veinte días.

Una vez sea firme la presente resolución, con testimonio de la misma devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: La precedente Sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente en el día de su fecha, de lo que doy fe.-